

1502528-30.2021.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/08/2022
... Data de Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502528-30.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502528-30.2021.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ARTHUR ALEJANDRO DA ROCHA ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ARTHUR ALEJANDRO DA ROCHA ARAUJO foi denunciado por incursão no art. 306 e no § 1º do art. 303 c.c o inciso I do §1º do art. 302, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia narra que, no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 10 horas, na Avenida Eugênio Negri, 534, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme laudo às fls. 16-8.

Descreve, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticou

lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vítima Thiago Henrique Barbosa Neves.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fls. 114 e 118) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa busca a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, sob regime penitenciário inicial aberto, além da substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação procede em parte.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08-12), laudo pericial de verificação de embriaguez (fls. 16-8), laudo de exame de corpo de delito da vítima Thiago (fls. 22-3) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 07). Sob o contraditório, admitiu a prática dos delitos (mídia digital).

A vítima Thiago, na fase administrativa, disse que (sic) "estava no interior do veículo VW/FOX, placa DUQ8493, conduzido por ARTHUR ALEJANDRO DA ROCHA ARAUJO, ocasião em que o depoente sofreu lesões leves" (fl. 06). Em juízo, afirmou que estava em uma festa na companhia do réu e depois pegou uma carona com ele, momento em que o acusado bateu o carro. Confirmou que o réu bebeu e não era habilitado (mídia digital).

A testemunha Francisco, na fase inquisitiva, historiou que (sic) "é proprietário do veículo HONDA/FIT, placa FR03H92 e na data dos fatos encontrava-se conduzindo seu veículo próximo à garagem da "Suzantur", em uma rua transversal à Rua Eugênio Negri, parado em um semáforo, quando o veículo VW/FOX, placa DUQ8493 colidiu na traseira do veículo do depoente; QUE logo em seguida o autor se evadiu do local, colidindo novamente o veículo, dessa vez com um muro; QUE o condutor estava visivelmente embriagado" (fl. 05).

Na fase antejudiciária, a testemunha Denis afirmou que (sic) "é proprietário do veículo VW/FOX, placa DUQ8493 há aproximadamente 02 meses, mas não tinha ainda transferido para o seu nome por pendências documentais; QUE na data de hoje, 30/10/2021, o depoente, ARTHUR ALEJANDRO e THIAGO HENRIQUE BARBOSA NEVES, estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas quando, por volta de 09h30min, deixou seu amigo ARTHUR ALEJANDRO dirigir o veículo, pois iriam para a "quadrinha" assistir um jogo de futebol; QUE em determinado momento, Na Av. Eugênio Negri, ARTHUR avistou uma viatura da Polícia Militar e se assustou, vindo a acelerar o veículo e acabou colidindo em uma parede; QUE o depoente permaneceu no local, mas não sabe indicar o motivo que THIAGO HENRIQUE tenha se evadido; QUE não sofreu lesões; QUE THIAGO estava bastante alterado; QUE não sabia que ARTHUR não era habilitado e que ele não aparentava estar embriagado, acreditando que ele tenha apenas se assustado" (fl. 04).

Os policiais militares, na fase administrativa, relaram que: (sic) "encontrava-se no interior da garagem da Suzantur, situado na AVENIDA EUGÊNIO NEGRI, 534 - JARDIM ZAIRA, realizando a limpeza da viatura policial, quando escutou um barulho de batida oriundo do lado de fora; QUE imediatamente foi até o local, ocasião em que populares indicaram que um indivíduo, ora identificado como THIAGO HENRIQUE BARBOSA NEVES, havia saído do veículo colidido e empreendido fuga; QUE perseguiu o autor, logrando êxito em abordá-lo em rua próxima, abordando-o; QUE, logo após, retornou para o local da colisão, ocasião em que constatou que o veículo VW/FOX 1.6, placa DUQ8493, havia colidido em um muro; QUE no interior do veículo, na condução, estava o nacional ARTHUR ALEJANDRO DA ROCHA ARAUJO, apresentando sinais visíveis de embriaguez, como fala "arrastada", odor etílico, olhos vermelhos; QUE no local havia também a testemunha DENIS CONCEIÇÃO SILVA, que relatou que também estava no interior do veículo; QUE o local do acidente restou preservado pela viatura M30132; QUE durante a condução dos envolvidos até o Distrito Policial, o nacional THIAGO HENRIQUE BARBOSA NEVES, extremamente alterado, começou a chutar a viatura policial, ocasião em que o depoente parou o veículo; QUE neste momento THIAGO saiu da viatura policial e passou a resistir, entrando em luta corporal com os policiais, tendo que ser utilizado os meios necessários para contê-lo; QUE, inclusive, seu companheiro de farda PATRIK SIMON RIBEIRO sofreu lesões leves em seu braço; QUE o condutor do veículo, ARTHUR ALEJANDRO, foi submetido à exame clínico, que constatou sua embriaguez; QUE ARTHUR não é habilitado para conduzir veículo automotor; QUE, antes de colidir no muro, o autor ainda colidiu em um outro veículo (Honda/FIT, placa FR03H92); QUE no local estava também a testemunha DENIS CONCEIÇÃO SILVA, que também estava no interior do veículo quando da colisão; QUE THIAGO HENRIQUE, também passageiro, sofreu lesões leves decorrentes da batida" (fls. 02-3). Em juízo, o policial militar Patrik confirmou a dinâmica do ocorrido. Disse que o réu foi abordado na condução do veículo, visivelmente embriagado. Constatou, ainda, que ele não possuía habilitação. Não soube dizer se houve lesão em decorrência do acidente (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha o entendimento do Pretório Excelso:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

No tocante ao crime de embriaguez ao volante, a prova oral colhida foi corroborada pelo laudo pericial de fls. 16-8, que concluiu que o acusado estava embriagado.

Ressalte-se que "o estado de embriaguez pode ser aferido por outros elementos de prova em direito admitidos, como na hipótese, em que, diante da recusa em fornecer a amostra de sangue para o exame pericial, o paciente foi submetido a exames clínicos que concluíram pelo seu estado de embriaguez" (STJ - HC: 151087 SP 2009/0205445-8, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ: 18/03/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2010).

Quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em que pese o laudo pericial de fls. 22-3 e a confissão, a denúncia não pode prosperar.

Melhor compulsando os autos, verifica-se que a inicial acusatória não descreve a quebra do dever de cuidado e em que consistiu a culpa do acusado, ou seja, eventual imprudência, imperícia ou negligência.

Não pode o magistrado, por dedução própria, referenciar a modalidade de culpa em que incorreu o réu, sob pena de ofensa ao princípio da correlação e ao sistema acusatório. Note-se que a denúncia e os memoriais escritos do Ministério Público não fazem menção à imprudência ou imperícia do réu, fato presumido pela condução do veículo após a ingestão de álcool e sem possuir habilitação.

Em síntese, a denúncia narra a conduta do réu, o resultado e o nexa causal, mas não a culpa, que não pode ser presumida. Sobre o tema, destaca-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O delito culposo exige a descrição da conduta culposa, com seu respectivo elemento caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia. Não se admite que, na peça acusatória, conste apenas um agir lícito (dirigir veículo automotor) e o resultado morte ou lesão corporal sem a efetiva demonstração do nexa causal, como por exemplo: ausência de reparos devidos no veículo, velocidade acima da média que, em tese, poderia impedir a frenagem a tempo ou outro dado concreto que demonstre a ausência de observância do dever objetivo de cuidado. 2. O simples fato de o réu estar na direção do veículo automotor no momento do acidente ou mesmo a perda do freio, por si só, não autoriza a instauração de processo criminal por crime de homicídio culposo ou lesão corporal culposa se não restar narrada a inobservância de dever objetivo de cuidado e o nexa de causalidade com o resultado. 3. No caso, a denúncia encontra-se amparada na narrativa de que "o veículo perdeu os freios e o denunciado aumentou a velocidade descendo a serra sem controle", o que não se revela suficiente para a aferição de eventual responsabilidade penal no evento narrado, devendo ser ressaltado que não foi realizada qualquer perícia nos freios ou na parte mecânica do caminhão ou sequer no local do acidente, não havendo lastro probatório mínimo para se apurar, justamente, o elemento normativo tipo, ou seja, a culpa por eventual imprudência, negligência ou imperícia do acusado. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a Ação Penal n.º 0000299-82.2012.815.0221. (STJ, HC n. 543.922/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020) g.n.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ARTS. 302 E 303 DO CTB. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA QUE OCASIONOU O RESULTADO. 1. A denúncia é inepta, pois não descreveu qual a conduta praticada pelo paciente, que decorreria de negligência, imprudência ou perícia, a qual teria ocasionado a produção do resultado naturalístico. 2. O fato de o paciente ter perdido o "controle da direção" e ter, em consequência, invadido a contramão, não é típico. A tipicidade, se houvesse, estaria na causa da perda do controle do veículo. Essa, entretanto, não é mencionada na peça acusatória. 3. Anulado o processo desde a denúncia, inclusive, verifica-se que se encontra extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB). 4. A pena máxima abstratamente cominada para o delito é de 6 meses a 2 anos de detenção. Portanto, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, prescreve em 4 anos, prazo há muito transcorrido desde a data da ocorrência dos fatos, em 4/10/2003. 5. O acréscimo decorrente do concurso formal não é levado em consideração no cálculo da prescrição, pela aplicação da regra do art. 119 do Código Penal. 6. Ordem concedida para anular a denúncia, em razão de sua inépcia, sem o prejuízo de oferecimento de outra devidamente corrigida, apenas no tocante ao delito tipificado no art. 302 da Lei n. 9.503/1997. Habeas corpus

deferido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade em relação aos crimes tipificados no art. 303 da mesma Lei, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 119 do Código Penal. (HC n. 188.023/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 26/3/2012) g.n.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Rejeição da denúncia por inépcia. Ausência de descrição da violação do dever de cuidado. Recurso desprovido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0008953-55.2015.8.26.0477; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/10/2021; Data de Registro: 04/10/2021) g.n.

APELAÇÃO CRIMINAL Crimes de trânsito- Embriaguez ao volante -Ausência de prova da materialidade delitiva -Inocorrência - Exame clínico e prova testemunhal confirmam a embriaguez - Lesão corporal na direção de veículo automotor - modalidade de culpa não descrita na denúncia - absolvição - Parcial provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 0003937-42.2015.8.26.0115; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campo Limpo Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017) g.n.

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CULPOSA - Crime de trânsito - Denúncia que não descreve a culpa que imputa, em evidente cerceamento de defesa - Processo anulado desde o início.(TJSP; Apelação Criminal 0003346-46.2014.8.26.0073; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2017; Data de Registro: 13/02/2017) g.n.

Nesses termos, necessária a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, passa-se à dosagem das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, na condução do veículo, visivelmente embriagado, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea'

(Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6). Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273). A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a

confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechado mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decísium, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão

Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUÉM DO PISO - SÚMULA 231, DO C. STJ. - REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.n.

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRg no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54).Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/03/2022).

Ainda assim, a reprimenda não poderia ser conduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, fixa-se em 02 meses.

O valor do dia-multa será o unitário mínimo.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena sob regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do par. 2º, do citado dispositivo legal, qual seja, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução.

Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu ARTHUR ALEJANDRO DA ROCHA ARAUJO, qualificado nos autos, às penas de 06 meses de detenção, sob o regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no unitário mínimo, substituída a pena corporal na forma acima especificada, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses, por infração ao art. 306 da Lei nº 9.503/1997, e ABSOLVÊ-LO da imputação de ofensa ao § 1º do art. 303 da Lei nº 9.503/1997, com espeque no inciso III do art. 386 do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita ao réu (fl. 195). Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella – Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA